

1500550-50.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Thiago trazia consigo, para o tráfico ilícito, 02 porções de maconha, bem como tinha em depósito, também para o tráfico ilícito, 01 tijolo e 02 porções grandes de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500550-50.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500550-50.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139218/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18066561 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2008/21/050

- DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2139218 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2008/21/050 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO GUILHERME DE ALMEIDA POMPIANI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Thiago Guilherme de Almeida Pompiani, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2021, às 12h30min, na Rua Conegundes Antônio de Brito, 2116, Bairro Jardim Silvestre, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, o acusado Thiago trazia consigo, para o tráfico ilícito, 02 porções de maconha, bem como tinha em depósito, também para o tráfico ilícito, 01 tijolo e 02 porções grandes de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo

de constatação preliminar (fls. 15/19) e laudo definitivo (fls. 140/142).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Em propedêutica análise (fls. 68/72), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 93/94, foram determinadas a notificação e citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 110), tendo o defensor público ofertado defesa preliminar (fls. 114/115).

Na decisão de fls. 124/125 houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 164/166 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 170/174 pugnando, em preliminar, pela nulidade da prova colhida, o que nulificaria o flagrante, e, em consequência, imporia a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II do CPP, e, no mérito, pela desclassificação para o delito de consumo pessoal, em síntese, pela quantidade de droga e forma de apreensão.

Já a Defensoria Pública às fls. 177/197 pleiteou, antes da análise do mérito, pelo reconhecimento da ilicitude da prova por derivação, com a consequente absolvição do acusado, ou, na questão de fundo, pela desclassificação da conduta para a contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou a aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei Antidrogas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

Inicialmente, a preliminar de nulidade da prova colhida merece ser ultrapassada.

Com efeito, importante citar que o alegado precedente invocado (HC nº 606583/SP, STJ), trata do seguinte fato: "O paciente foi denunciado como incurso às penas do artigo 33 da lei 11.343/2006, por ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Segundo consta, militares receberam denúncia anônima de que o paciente estava embalando entorpecentes para colocar à venda. Os policiais narraram que chegaram até a casa do denunciado e o portão estava encostado, motivo pelo qual, adentraram ao imóvel e avistaram o paciente separando maconha. Durante a instrução, os militares deixaram claro que ao chegarem defronte ao imóvel, não conseguiram visualizar o paciente, motivo pelo qual, adentraram e viram o acusado sentado na mesa embalando os entorpecentes. Interrogado, o paciente confessou que adquiriu os entorpecentes para posterior comercialização, ante a sua grave situação financeira, mas, antes de conseguir realizar a primeira venda, foi surpreendido pelos milicianos. Aduziu também, que não franqueou a entrada dos militares em sua residência, muito menos sua esposa, que, quando da invasão, estava na cozinha preparando o jantar."

Portanto, no citado remédio heroico, o paciente guardava ou tinha em depósito a droga.

Em outras palavras, estava ele dentro da residência quando da abordagem.

Por isso, os fatos não são análogos.

Deste modo, não pode a mencionada garantia constitucional ser vista como precedente, conceito que pode ser extraído, a contrario sensu, do art. 926, §2º do CPC, em aplicação analógica: "Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (...) § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação".

Não obstante, na hipótese em exame, anteriormente à alegada "invasão" da residência, foi o acusado abordado, ocasião em que foi encontrado dinheiro (R\$ 414,00), além de duas porções de maconha nos bolsos da calça. Portanto, veja-se que na parte externa da residência, o réu já foi encontrado com droga e com quantia em dinheiro em notas trocadas.

Além disso, o acusado possui "histórico criminal" em crimes de tráfico, o que, aliado ao "nervosismo" apresentado durante a abordagem, encontro de droga e numerário denotam que a fundada suspeita estava evidenciada no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE

DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, 1ª Turma, HC 202339 AgR / SC - SANTA CATARINA, relatora ministra Rosa Weber, julgado em 17/08/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS, OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO FORÇADO QUE NÃO OBSERVOU AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE E DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DA POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.

II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - No caso dos autos, consoante consignado pelo eg. Tribunal de origem, os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina, visualizaram o ora paciente em atitude suspeita, portando arma fogo. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado evadiu-se para o interior do seu domicílio onde jogou a arma de fogo.

IV - Ato contínuo, os agentes foram em busca do paciente e da arma, cuja dispensa visualizaram previamente, tendo encontrado ainda grande quantidade e variedade de drogas (fl. 290), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 701218 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 13/12/2021)

Por tudo, fica a preliminar afastada.

No mérito, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/19) e laudo definitivo (fls. 140/142).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Denis Valdivino dos Santos, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em resumo, que, em patrulhamento pelo bairro Silvestre, houve fundada suspeita da prática de crime pelo acusado estar nervoso. Afirmou que abordagem foi feita em

frente à residência e encontro de ilícito nos bolsos das calças. Informou que ele indicou onde estaria o restante das drogas na residência, sendo que a mãe dele acompanhou as diligências. Esclareceu que, na casa, havia tijolos de maconha, enquanto que, com o acusado, havia porções da mesma droga. Mencionou que os tijolos possivelmente seriam vendidos, já que o acusado afirmou que passaria a droga para outra pessoa. Citou que a ação policial ocorreu na hora do almoço. Asseverou que o acusado estava sozinho, sentado em frente da casa. Disse que o acusado estava muito nervoso, por isso a fundada suspeita. Afirmou que o acusado indicou, voluntariamente, o cômodo onde havia mais droga. Informou que teriam chegado à droga, mas o trabalho foi facilitado.

O policial militar Gabriel Henrique Ruiz Dias, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que estavam em patrulhamento, e se depararam com o indivíduo com volume na cintura, sendo que estava com drogas nos bolsos. Afirmou que o portão da casa estava aberto e o acusado confessou onde elas estavam. Informou que localizaram também uma faca. Esclareceu que o acusado confessou o delito. Mencionou que a parte maior da droga foi descoberta com a ajuda do acusado. A informante Rosemeire de Almeida, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que é mãe do acusado e que ela não estava presente no local dos fatos. Afirmou que foi ao mercado e, quando voltou, seu filho estava algemado no quintal da residência. Informou que seu filho é inocente. Esclareceu que o acusado é usuário de maconha. Mencionou que os três policiais estavam no quintal. Citou que o acusado estava de "saidinha" (três dias).

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até por que não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Thiago sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que estava na casa da mãe (saída temporária). Afirmou que comprou droga para uso e estava no quintal de casa. Informou que ouviu barulho, quando os policiais entraram em sua casa. Esclareceu que comprou a quantia de R\$ 1.000,00 em droga. Alegou que

'não pensou sobre a quantidade que comprara'. Citou que dormia no quarto da mãe. Asseverou que o dinheiro não era proveniente da droga, mas do trabalho prestado perante a Penitenciária. Disse que a casa não é dele, e que os policiais o ameaçaram.

Pela prova colhida, a meu ver, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Assim, a desclassificação para o delito de consumo é inviável.

Os policiais mencionaram que o acusado foi abordado, e, com ele, foram encontradas duas porções de maconha, mais precisamente em seu bolso e, em seguida, grande quantidade de droga (da mesma espécie) no interior da residência dele.

Assim, após, com a entrada no domicílio, os policiais encontraram o restante da droga, como dito, da mesma natureza, ainda em forma de "tijolo".

Importante citar, no aspecto, que o próprio acusado, diversamente do afirmado pela genitora, disse que pernoitava em um quarto, sozinho, onde foi encontrado o entorpecente, em 'um armário do tipo cabeleireiro' (fls. 05/06).

Aliás, durante o próprio interrogatório judicial, o acusado mencionou que teria comprado toda a droga (quase um quilo, por cerca de R\$ 1.000,00).

Contudo, diversamente do afirmado, não seria o entorpecente para consumo pessoal.

O réu, durante a audiência, não conseguiu elucidar a necessidade de compra do citado montante.

Ademais, de se citar que estava de "saidinha" há apenas três dias, e que possui dupla reincidência específica, em seu desfavor (feitos nº 0001198-46.2017.8.26.0594 e 0004819-78.2011.8.26.0071, fls. 42/45).

Não se pode olvidar ainda, que na residência foram apreendidos faca, elástico, rolo de plástico (petrechos típicos da traficância), além de dinheiro, montante cuja procedência não foi elucidada (fls. 12/13).

Portanto, os termos do art. 28, §2º da Lei Antidrogas, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado Thiago permanecer custodiado.

Como dito, o acusado possui duas reincidências específicas em seu desfavor.

Depois, descumpriu aos ditames da saída temporária, nos termos do art. 125 "caput" da LEP: "Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso".

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. ENVOLVIMENTO DE MENOR E HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA NATUREZA. DELITO COMETIDO DURANTE O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. RISCO DE CONTINUIDADE NA ATIVIDADE CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO E IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada pelo seu histórico criminal, indicativo de dedicação à narcotraficância.

2. O fato de o agente envolver menor na prática criminosa e possuir condenação anterior pelo mesmo tipo de delito é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir - sobretudo porque havia sido beneficiado com saída temporária na condenação anterior e não retornou ao estabelecimento prisional, cometendo o novo delito -, autorizando a preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis - não comprovadas, diga-se -, não teriam o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

4. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da alegada desproporcionalidade da constrição em relação a eventual condenação do agente e da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, quando as questões não foram analisadas no aresto combatido.

5. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ, 5ª Turma, RHC 64384 / MG, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 03/12/2015)

Passo à fixação da pena.

Réu Thiago Guilherme de Almeida Pompiani

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade de droga (quase um quilo de maconha), denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é multireincidente (dois outros delitos de tráfico). Deste modo, também possui reincidências específicas em seu desfavor.

Tais circunstâncias sugerem que as agravantes sejam valoradas com maior rigor, forte na própria individualização da pena.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Assim, a pena deve ser agravada em 1/5, atingindo 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) diárias.

Na derradeira, inaplicável a redutora prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06.

Para fins de elucidação segue a transcrição do dispositivo legal: "Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços".

Da análise do caso concreto, forçoso convir que o acusado não colaborou

voluntariamente com a investigação policial (ainda que aqui seja vista em sentido amplo).

Aliás, no próprio interrogatório o acusado afirmou que foi ameaçado e nada mencionou sobre a indicação da droga.

Ademais, os policiais citaram que chegariam à droga ainda que não houvesse "ajuda". Depois, não foram observados os requisitos cumulativos da identificação de co-autores e partícipes e recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. Quanto ao último (produto do crime), a droga não pode ser considerada ao desiderato.

Ocorre que "produto" é consequência da prática do delito, e, por isso, deve ser lícito.

O entorpecente, de per si, é ilícito, além de constar como elementar do próprio delito.

Por tais razões, a minorante não pode ser aplicada.

Assim, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Thiago é multireincidente específico.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da

Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e desta feita, CONDENO o réu Thiago Guilherme de Almeida Pompiani, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) diárias, em regime inicial fechado, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado Thiago o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados. Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/34. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos aparelhos celulares e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA